

1500790-24.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... que, informalmente, Jenifer confessou o tráfico e delatou a participação do corréu. Bruno negou a prática de tráfico aos agentes municipais.

As testemunha de defesa nada de relevo trouxeram aos autos. Nenhuma presenciou a abordagem.

A ré, em juízo, confessou a autoria do tráfico, isentando de responsabilidade seu comparsa.

O acusado, por sua vez, disse ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500790-24.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500790-24.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BRUNO HENRIQUE DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de processo-crime contra BRUNO HENRIQUE DA SILVA e JENIFER CRISTINA LORENA FURTUOSO, já qualificados, por suposta prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.128 e 132.

Defesa Preliminar às fls. 119/122.

A denúncia foi recebida às fls.134/135.

Citação às fls.172 e 174.

Em audiência de instrução foram ouvidas quatro testemunhas e interrogados os acusados (fls.182/187).

As partes apresentaram memoriais.

Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia.

Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas e outros benefícios legais subsidiariamente.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva estatal.

Materialidade demonstrada pelo boletim de fls.09/10, auto de exibição de fls.13 e laudo de fls.89/91.

A autoria é certa.
Vejam os:

Os guardas municipais, ouvidos em juízo e no auto de flagrante prisional, foram uníssonos e firmes ao relatar que, em patrulhamento de rotina em afamada "biqueira", avistaram a ré Jenifer entregando algo ao condutor de bicicleta. Este, ao notar a presença dos guardas, gritou "polícia!!", advertindo os demais e empreendeu fuga. O acusado Bruno estava ao lado de Jenifer e, ao notar que seria abordado, se desfez de sacola que trazia consigo. Em revista pessoal, localizaram com a denunciada quatro "pinos" de cocaína e 20 reais. Ato contínuo, recuperaram a sacola jogada por Bruno, dentro da qual localizaram 90 porções de cocaína e 24 "pedras" de crack. Disseram ainda que, informalmente, Jenifer confessou o tráfico e delatou a participação do corréu. Bruno negou a prática de tráfico aos agentes municipais.

As testemunhas de defesa nada de relevo trouxeram aos autos. Nenhuma presenciou a abordagem.

A ré, em juízo, confessou a autoria do tráfico, isentando de responsabilidade seu comparsa.

O acusado, por sua vez, disse ser usuário e que ali estava apenas para comprar drogas após discussão com sua esposa.

São as provas. A condenação é de medida imperiosa.

Nesse diapasão, lembre-se que, sobre a validade probatória das falas dos servidores públicos que participaram da prisão ou investigação, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido:

"Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o

apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade." (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

No mesmo sentido, André Estefam ensina que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e Procedimentos no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, pag. 55), de forma que o ônus de prova tendente a desqualificar o testemunho do agente é da Defesa, que deverá trazer elementos concretos a desmerecer o testemunho prestado pelo agente estatal.

Trata-se, na verdade, da aplicação da regra do ônus da prova prevista no art. 156, do CPP.

De fato, como se sabe, "A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156 ...). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais (...)" (Curso de Processo Penal, 20a. Edição, ed. Saraiva, 2013, CAPEZ, Fernando, p. 410) .

Entretanto, importante ressaltar que "a prova da acusação há de ser plena e convincente, enquanto que para o acusado basta a dúvida, já que tem por si a presunção de inocência. Dispõe, com efeito, o art. 386, VI, do Código que o juiz absolverá o réu "se não existir prova suficiente para a condenação" (BARAUNA, José Roberto. Lições de Processo Penal, 2a. Edição, editora José Bushatsky. São Paulo, 1979, p. 1255).

Assim sendo, caberia à Defesa, ao impugnar a validade dos testemunhos dos agentes estatais, ao menos, semear dúvida razoável sobre a parcialidade. Não o fazendo, como não o fez no caso em testilha, eventuais alegações de inidoneidade dos servidores estatais não pode ser acolhida.

De fato, "o acusado deve apenas atuar no sentido de apresentar dúvida razoável no espírito do julgador e não de prova plena das excludentes acima mencionadas" (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela acusação). (DEZEM, Guilherme Madeira, Curso de Processo Penal, 2a. Edição. São Paulo, editora Revista dos Tribunais, 2016; p. 472).

Ademais, os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

No mais, não há falar-se em ilegalidade na atuação dos guardas municipais, eis que

a prisão se deu em flagrante delito notório durante atividade rotineira dos servidores em patrulhamento de vias públicas municipais.

Recordo que "(...) Os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (STJ) (...)” (TJSP, 10a. Câmara de Dir. Criminal, HC 2165657-91.2022.8.26.0000, de relatoria do Des. Adilson Paukoski Simoni; Data do Julgamento: 31/08/2022).

Havia ainda justa causa para a abordagem pessoal realizada pelos agentes municipais. Nesse diapasão:

“(...) Guardas municipais que realizaram busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Réu que estava parado em local conhecido pelo intenso comércio de substâncias ilícitas. Réu que, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica que trazia nas mãos. Comportamento suspeito que sustentou a abordagem. Justa causa para a medida. Busca necessária em contexto de preservação da integridade física dos guardas. Ilegalidade afastada. Precedentes.” (TJSP; Apelação Criminal 1525695-42.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022).

A mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo.

Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJ TJ 101/498).

Assim, entendo não ser o caso de se desclassificar a conduta para o tipificado no art. 28 da Lei Antidrogas, eis que a destinação ao comércio ilegal resta evidente pela quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, a maneira como se deu a ocorrência (ré flagrada em ato típico de venda de drogas), em local já conhecido pela venda de entorpecentes.

Irrelevante, em especial em relação ao corréu Bruno, ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

De fato, tratando-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado - que, segundo o Professor Damásio de Jesus, “são crimes em que o tipo faz referência a várias modalidades da ação” - o delito estará consumado com a prática de um ou mais de um dos verbos nucleares, (Direito Penal, 10. Volume, Parte Geral, 6a. Edição, editora Saraiva, 1980, p. 200)

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, “ex vi”:

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer

das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câ., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denner de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A condenação é, portanto, de rigor.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase.

Conforme o consignado no art. 42, da Lei de Drogas, tem-se que a quantidade, diversidade e natureza das drogas devem ser os critérios diferenciadores das penas aplicadas aos variados "tipos" de traficantes, do pequeno ao grande e de drogas diversas.

Isso porque, tais critérios legais - quantidade, diversidade e natureza da droga - evidenciam presente maior ou menor reprovabilidade da conduta.

Assim sendo, quanto maior a capacidade de viciar da droga, maior a reprovabilidade, justificando-se o aumento da pena.

E também o C. Supremo Tribunal Federal. "Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a natureza e a quantidade do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06" (STF HC nº 112798 / AC rel. Min. Carmen Lúcia j. 18/12/2012)

Reforçando a tese acima exposta, sobre o tema, nossos Tribunais já fixaram entendimento de que, em se tratando de "crack", a penabase deve ser majorada. Vejamos:

"(...)a penabase foi fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, (...), tendo em vista a especial gravidade das circunstâncias fáticas do crime que envolvia o nefasto comércio ilegal de "crack", nos termos expendidos pelo art. 42, "caput", do Código Penal. (...) a potencialidade lesiva do crack e as consequências sociais do seu comércio ilegal acarretam clara violação à saúde e segurança pública, bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico" (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000164- 38.2012.8.26.0262, da Comarca de Itapeva, de relatoria do Des. Salles de Abreu, em 16 de abril de 2013)

"DOSIMETRIA - AGENTE FLAGRADO COM CRACK - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO - Insuficiência: Além da maior gravidade da oferta de crack, substância com maior poder devastador, a quantidade de drogas aponta necessidade de maior reprovação da conduta e, por isso, insuficiente a manutenção da pena mínima. Recurso parcialmente provido, somente para redução das penas." (TJSP, 15ª Câ. Dir. Criminal, Apelação nº 0005278-47.2011.8.26.0664, de relatoria do Des. J. Martins, São Paulo, 04 de abril de 2013).

No caso em julgamento, os réus foram presos, e agora condenados, por tráfico relacionado a expressiva quantidade (118 porções) de duas espécies de drogas diversas (cocaína e crack), merecendo, pois, o incremento da pena.

Aumenta-se, assim, em relação à Jenifer, a pena em 1/6.

Em relação ao réu Bruno, deve-se ainda levar em conta os maus antecedentes (fls.100 - autos 1501616-89/2019), justificando-se aumento em 1/5 (já considerada natureza e quantidade das drogas e vida pregressa).

Segunda fase. A ré Jenifer é menor de 21 anos e confessou a prática delitiva, razão pela a pena deve retornar ao patamar raso.

O condenado Bruno, de modo diverso, é reincidente (autos 3065-61/2014 - fls.99), justificando-se novo aumento em 1/6.

Terceira fase. Ao réu Bruno inviável a aplicação do redutor por ser reincidente e portador de maus antecedentes.

Nada impede, porém, a redução da pena em relação a condenada Jenifer, eis que primária, de bons antecedentes e sem prova de envolvimento em organização criminosa.

Ressalto aqui que natureza e quantidade das drogas já foram consideradas na fase inicial, sendo vedado o "bis in idem".

A par disso, "O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que 'A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior.'" (STJ, HC Nº 664.284 - ES, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, 5ª. Turma, em 21 de setembro de 2021).

E mais:

"Na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante. 2. Além disso, a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si só, o afastamento da referida minorante ou a modulação da fração de diminuição, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 699.676/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/11/2021).

Forte em tais premissas, reduzo a pena em 2/3, eis que vedada a reutilização dos fundamentos já considerados na fase exordial (por conta de pleito expresso do órgão ministerial), a saber, natureza, quantidade e diversidade para justificar redução aquém do máximo.

Regime inicial. Ao condenado Bruno, por conta de sua vida pregressa, o regime deverá ser o inicial fechado.

Impossível a progressão antecipada do art. 387, §2º, do CPP, eis que adimplido o requisito temporal previsto no art.112, da LEP (50% da pena aplicada).

Para Jenifer, uma vez reconhecido o tráfico privilegiado, conforme deliberado pelo

E. STJ (tema 600), não há óbice à fixação de regime aberto, com a possibilidade de substituição por restritivas de direitos (o que será feito a seguir).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para:

A) CONDENAR o réu BRUNO HENRIQUE DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal; e para,

B) CONDENAR a ré JENIFER CRISTINA LORENA FURTUOSO, já qualificada, como incurso no crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade de JENIFER, em observância ao deliberado pelo E. STJ (Tema 600), por uma restritiva de direito e uma multa, a saber: a) prestação de serviços sociais, a ser oportunamente especificada pelo juízo da VEC; e multa de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Custas processuais em 100 UFESPs pelos condenados.

Mantenho a prisão cautelar de Bruno para garantia da ordem pública em razão de seus antecedentes.

Jenifer poderá recorrer em liberdade.

Determino o perdimento do numerário apreendido, bem como a destruição dos entorpecentes. Providencie-se o necessário, com urgência, inclusive certidão de honorários.

PRIC.

Araras, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA